



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2019.0000211087

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0012485-75.2013.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALZINETE GONSALVES DA SILVA, é apelado PAULO BENJAMIM RODRIGUES DE LIMA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCIA DALLA DÉA BARONE (Presidente sem voto), JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES E JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.

São Paulo, 22 de março de 2019.

Rosangela Telles
Relatora
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO Nº: 12750

APELAÇÃO Nº: 0012485-75.2013.8.26.0002

APELANTE: A.G.S.

APELADO: P.B.R.L.

COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTO AMARO

JUIZ: EDILIZ CLARO DE VICENTE REGINATO

APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA. JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. Inocorrência. Nas demandas que envolvem o interesse de menor, o magistrado deve observar sempre o bem estar e o desenvolvimento da criança, não ficando adstrito ao pedido formulado na exordial. Preliminar rejeitada. FIXAÇÃO DE VISITAS PATERNAS MONITORADAS. Cabimento. Embora o estudo psicológico tenha apontado para a existência de abuso sexual pelo genitor, não há prova cabal de tal conduta nos autos. Beligerância entre as partes que coloca em dúvida a realidade dos fatos. O próprio infante, inclusive, manifestou seu anseio em retomar o contato com o pai, de modo que a sua vontade deve ser considerada, nos termos do art. 28 do ECA. Manutenção das visitas que não importa em risco à integridade física e psicológica do menor, uma vez que elas serão realizadas de forma monitorada e por pessoa de confiança da genitora. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 137/139, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente demanda para atribuir à apelante a guarda unilateral do menor MURILO, resguardado o direito de visita por parte do apelado, quinzenalmente, aos sábados, das 12h às 18h, desde que acompanhado por pessoa de confiança da genitora. Ainda, condenou o apelado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por equidade em 10% do valor da causa, ressalvada a gratuidade de justiça.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Embargos declaratórios acolhidos pelo MM. Juiz *a quo*, tão somente para determinar a expedição de certidão de honorários à advogada dativa nomeada (fls. 156).

Inconformada, a apelante sustenta a ocorrência de julgamento *extra petita*, no tocante à fixação do regime de visitas em favor do genitor. Alega que não fora realizado qualquer pedido nesse sentido, tendo o MM. Juiz *a quo* extrapolado os limites objetivos da petição inicial. No mérito, afirma que o apelado não comprovou ter condições de conviver com o infante, sobretudo diante das graves acusações de abuso sexual descritas nos autos. Pugna, assim, pela revogação das visitas concedidas em primeira instância, devendo tal questão ser discutida em ação própria, sob pena de se causar graves prejuízos à criança. Busca a reforma do *decisum*.

Recurso tempestivo e regularmente processado, encontrando-se presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (fls. 173/174).

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. sentença guerreada fora proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Quando da interposição deste recurso já vigia a Lei n. 13.105/2015, motivo pelo qual as disposições desta legislação devem ser observadas.

Cabe afastar, outrossim, a alegação de nulidade do *decisum*, em virtude de julgamento *extra petita*.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Com efeito, sabe-se que nas demandas que envolvem o interesse de menor, o magistrado deve observar sempre o bem estar e o desenvolvimento da criança, não ficando adstrito ao pedido formulado na exordial.

Nesse sentido:

"Julgamento 'ultra petita. Ação de modificação de guarda, na qual o magistrado deixa de acolher este pedido, fixando, porém, regime de visitação diverso daquele que consta em acordo feito pelas partes. Nulidade. Não caracterização. **Decisões proferidas em ações que envolvem guarda e visita a menor que devem sempre visar ao bem-estar e desenvolvimento da criança. Desnecessidade de o juiz ficar adstrito ao pedido.** Recurso improvido". (TJSP, Apelação nº 0123961-71.2006.8.26.0000, Rel. Des. Álvaro Passos, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 15/06/2014) (g.n.)

"Apelação cível. **Ação de modificação de guarda. Improcedência, com ampliação das visitas acordadas. Possibilidade. Preliminares de julgamento 'extra' ou 'ultra petita'**, bem assim, de afronta ao contraditório, incompetência do juízo e litispendência parcial, afastadas. **Juízo que obedeceu ao princípio do melhor interesse das crianças**, sendo cediço que já estão cumprindo outro regime de visitas, mais amplo, inclusive, fixado por ocasião da tutela antecipada. Sentença mantida. Recurso improvido". (TJSP, Apelação nº 0022449-49.2010.8.26.0309, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 15/07/2014) (g.n.)

Desse modo, tem-se que a regulamentação do regime de visitas pelo juízo de origem, ao contrário do sustentado pela apelante, não acarreta a ocorrência de nulidade, mesmo que inexistente qualquer pedido nesse sentido, tendo em vista a natureza da presente ação e a necessidade de proteção dos interesses da menor em questão.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Superada a preliminar arguida, passo ao exame do mérito.

Cuida-se de ação de fixação de guarda ajuizada por A.G.S., ora apelante, em face de P.B.R.L., ora apelado, aduzindo, em síntese, que as partes mantiveram um relacionamento amoroso, do qual nasceu o menor M.G.R.L., em 09/08/2007 (fls. 12/13).

Afirma que, diante dos conflitos vivenciados, o casal rompeu em maio de 2012, ficando a criança sob os cuidados da genitora, a qual autorizava que o pai exercesse o direito de visitas ao filho quinzenalmente, retirando-o aos sábados e devolvendo-o nos domingos.

Ocorre que, certo dia, o infante MURILO informou à apelante que o apelado lhe obrigava a segurar seu pênis ereto, bem como se deitava nu ao seu lado.

Daí a propositura da presente demanda, pretendendo a apelante justamente a atribuição da guarda definitiva em seu favor, além da suspensão do direito de visitas paternas, em virtude do abuso sexual praticado.

Regularmente citado, o apelado contra-atacou os argumentos apresentados na exordial, defendendo a idoneidade da sua conduta e a prática de alienação parental pela genitora (fls. 26/29).

Foram realizados os estudos pertinentes (fls. 66/73 e fls. 103/107).

O feito seguiu regularmente e, ao final, o D. Magistrado *a quo* entendeu ser o caso de julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na demanda, nos seguintes termos:

Em face do exposto julgo parcialmente procedente a ação de guarda, para o fim de fixar à autora a guarda unilateral do filho M.G.R.L., e para



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

regulamentar as visitas do genitor ao menor quinzenalmente, aos sábados, das 12h às 18h horas, devendo tais visitas serem acompanhadas por pessoa de confiança da autora. Desse modo, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. Expeça-se termo de guarda por prazo indeterminado. Diante da sucumbência maior por parte do requerido, condeno-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3º/NCPC, vez que o réu é beneficiário da gratuidade processual. Após o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais arquivem-se os autos. P.R.I.C.

Exatamente contra esta r. sentença que se insurge a apelante, limitando-se a discussão, nesta sede recursal, apenas ao regime de visitação estabelecido em primeira instância.

Como sabido, tanto a guarda como a visitação devem atender sempre ao melhor interesse da criança, observando-se a distribuição de tempo necessário ao convívio com os genitores, o aspecto econômico, as circunstâncias de natureza afetiva e pessoais, entre outras passíveis de consideração¹.

Em outras palavras, a proteção dos interesses do menor envolvido sobrepõe-se a qualquer outro bem ou interesse juridicamente tutelado, levando-se em conta a destinação social da lei e o respeito a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

Na lição de Rolf Madaleno, “o critério do interesse do menor só adquire eficácia quando examinada a situação de fato, a partir da consideração de elementos objetivos e subjetivos da casuística, tendo a jurisprudência permitido identificar algumas tendências no tocante às relações afetivas da criança e sua inserção no grupo social, como apego que ela manifesta em relação a um de seus genitores; o cuidado para não separar irmãos, as condições materiais, tais como o alojamento e as facilidades escolares e morais; o vínculo de afetividade entre o pai e o filho, seu círculo de amizades, ambiente social, qualidade de cuidados e etc²”.

Tem-se ainda que o regime de visitas é direito não só dos

¹ Arnaldo Rizzardo, Direito de Família, 2ª. Edição, Forense, p. 334.

² Curso de Direito de Família, 1ª ed., Rio de Janeiro, Forense, p. 273.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

genitores, uma vez que se trata de direito-dever que decorre do exercício do poder familiar, mas também dos filhos, já que a convivência com os pais é de extrema importância para o crescimento e desenvolvimento do infante.

De acordo com o artigo 1.589 do Código Civil, *“o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação”*.

Desse modo, é direito que deve ser garantido e prestigiado, contanto que observado o princípio da prevalência do interesse do menor, não podendo ser retirado ou restringido, a não ser em casos excepcionais.

In casu, verifica-se que o menor MURILO conta atualmente com onze anos de idade (fls. 12/13) e se encontra bem amparado pela genitora, razão pela qual lhe fora atribuída a guarda unilateral do infante, inexistindo controvérsia quanto a este ponto.

Em relação à visitação, por sua vez, verifica-se que o laudo de fls. 66/73 apontou, de fato, para possível existência de abuso sexual pelo genitor.

Nas palavras da psicóloga judiciária, *“Murilo expressou, por meio de sua produção gráfica, ter sido exposto a situações inadequadas a uma criança, que podem ser consideradas situações de abuso sexual. O conteúdo de seus desenhos revela que a criança associa o genitor ao órgão genital masculino e, ainda, que o infante foi instado a participar de cenas de conotação sexual em companhia do genitor. Suas produções gráficas e seu discurso sobre elas indicam que a criança, incapaz ainda de entender o significado das atitudes paternas, considera o pai uma vítima, ou um ‘doente’, por tê-lo denunciado e assume a culpa pela sua ausência”* (fls. 72).

Todavia, em que pese a conclusão exposta no estudo psicológico, é certo que não há prova cabal das gravíssimas acusações perpetradas contra o apelado. Este, aliás, refutou expressamente as afirmações da apelante, aduzindo serem todas inverídicas, não tendo jamais exposto seu filho à situação semelhante.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Alegou que há grande animosidade entre as partes, desde a separação, circunstância que acaba por influenciar no comportamento da genitora, que busca de todas as formas afastar o menor da companhia paterna.

Juntou com a contestação declarações de terceiros atestando a idoneidade do seu caráter e da sua reputação (fls. 35/33).

Ainda, durante o estudo social, alertou para a crise conjugal vivenciada pelo casal, para os problemas que teve com outros companheiros da apelante e os supostos artifícios utilizados pela ex-mulher para lhe prejudicar (fls. 105):

(...) A crise conjugal teve início quando começou a emagrecer e sentir fraquezas, comprometendo o seu desempenho sexual. O diagnóstico médico correto levou tempo e uma peregrinação em postos de saúde e prontos-socorros, até que o hipertireoidismo foi descoberto e tratado. Hoje está sob controle, mas chegou a pesar 58 kg. Segundo Paulo, neste ínterim a Sra. Alzinete se apaixonou por outra pessoa e parecia estar em dúvida com quem ficar. Acabou optando pelo pai de Guilherme, que logo foi morar na casa dela. Era um rapaz que agia de maneira violenta e que o ameaçava constantemente, tentando o afugentar das visitas de Murilo. Logo que engravidou, o pai de Guilherme a abandonou. Depois da acusação de abuso, Paulo lembrou do quanto era manipulado por Alzinete a ser temperamental com o pai de Carol, quando ele ligava para ter notícias da filha. Conta também que Alzinete recortou todas as fotografias em que o ex aparecia, não deixando qualquer lembrança da figura dele para a criança. O entrevistado acredita que Alzinete se arrependeu da escolha e como não quis se reconciliar, acabou sofrendo a queixa. Relata também que a notícia de abuso foi espalhada pelo bairro pela própria mãe, com o intuito único de lhe prejudicar. Depois ela se mudou do bairro na calada da noite e não lhe forneceu o endereço. Lembra que comprou um boneco para o filho, mas o presente ficou dias na portaria, sem ser retirado.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

A apelante, de outra banda, também relatou a relação conflituosa do casal, sob o seu ponto de vista (fls. 67):

(...) Namorou o requerido durante um ano, noivaram e decidiram coabitar um imóvel. A autora já era mãe da Carolina, hoje com dezenove anos de idade e casada. Nessa ocasião, a menina contava com dez anos de idade. O Sr. Paulo era adepto ao consumo de bebidas alcóolicas, o que fazia todos os dias, e manifestava ciúme da relação entre a requerente e a filha. Ela se preocupava com a segurança de Carolina e mantinha atenção redobrada ao comportamento do requerido em relação à menina. Embora o ambiente familiar fosse muito "pesado" em virtude do comportamento ciumento e insatisfeito do companheiro, a autora engravidou. O período gestacional foi sofrido, pois ela tinha problemas de saúde, foi acometida por depressão e a gravidez tornou-se um risco. O companheiro não colaborava e ainda a acusava de não fazer nada direito.

Percebe-se, portanto, que as partes possuem um histórico de brigas e desentendimentos mútuos, cujos conflitos provavelmente se agravaram após o fim do relacionamento. A beligerância entre ambos, por certo, coloca em dúvida a realidade dos fatos.

Isto é, o contexto dos autos não permite dar guarida, de forma segura, às alegações de qualquer das partes, haja vista a dualidade das teses trazidas e a animosidade existente entre os litigantes.

Assim, não obstante o laudo psicológico aponte indícios de suposto abuso sexual por parte do apelado, não há elementos sólidos de convicção que permitam concluir, com exatidão, pela prática de tal conduta.

Ressalte-se que, segundo o apelado, "o filho era muito vinculado a ele, e como Alzinete trabalhava nos finais de semana, ficava com o garoto de sexta até domingo, quando costumavam jogar bola, vídeo game e ver TV. O pai segue contanto que também percebeu comportamento estranho em Murilo e um



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

linguajar diferente. Disse que ouviu o menino falando 'piroca' quando assistia um desenho da TV e o repreendeu por isso. Acredita que o menino pode ter visto relações sexuais da mãe ou da irmã, já que na época moravam em um apartamento pequeno, onde não havia privacidade” (fls. 106).

A despeito da credibilidade ou não do argumento apresentado pelo apelado perante a assistente social, há que se consignar que não ficou cabalmente comprovada a sua conduta desabonadora, tal como já exposto, não podendo se afirmar também nestes autos qual teria sido a causa que desencadeou o transtorno de hipersexualidade em MURILO.

Uma coisa, no entanto, é certa. O infante manifestou expressamente o seu desejo em retomar o contato com o pai.

De acordo com o laudo, “*por um lapso, agendamos os estudos da Requerente e do Requerido num horário próximo e as partes se encontraram no saguão. Durante a entrevista de Alzinete, Murilo permaneceu do lado de fora na companhia do segurança e, segundo este, quando o pai chegou, a criança reagiu normalmente, cumprimentou com um beijo no rosto e mostrou o jogo do celular. Em situação de entrevista, (...) Murilo disse que gostou de ver o pai no Foro, demorou um tempo para reconhecê-lo, porque não lembrava que ele tinha espinhas no rosto. **Questionado, afirmou ter interesse de encontra-lo outras vezes**” (fls. 106).*

Logo, a vontade da criança deve ser considerada, nos termos do art. 28, §1º, do ECA, que assim dispõe:

Art. 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta Lei.

§1º Sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

implicações da medida, e terá sua opinião devidamente considerada.

Destarte, há que se manter o direito de visitas do apelado ao seu filho, tal como já estabelecido em primeira instância, cuja medida não importa em risco à integridade física e psicológica do menor, uma vez que elas serão realizadas de forma monitorada e por pessoa de confiança da genitora.

A propósito, cumpre anotar que nem mesmo a Procuradoria de Justiça, legitimada para defender os interesses do infante, se opôs à visitação.

Sendo assim, de rigor a manutenção do r. *decisum*, ficando ressalvado que, futuramente, havendo elementos a recomendar a suspensão do regime de visitas, o pleito poderá ser objeto de reapreciação, pois o que se sobreleva são os interesses da criança.

Na hipótese de interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1º da Resolução nº 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.

Alerto, ademais, que não é necessária a interposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria questionada está automaticamente prequestionada.

Posto isso, pelo meu voto, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso.

ROSANGELA TELLES

Relatora